

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2623/2565

พนักงานอัยการจังหวัดกระบี่
นางสาว ช.

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 มาตรา 49 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กำหนดว่า ผู้ใดประสงค์จะเป็นมัคคุเทศก์ก็ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากนายทะเบียน การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งถือเป็นบทกฎหมายที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการประกอบอาชีพ และมีการกำหนดโทษทางอาญาไว้ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การพิจารณาว่าใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ บัตรสีชมพู มีเงื่อนไขห้ามนำเที่ยวทางทะเล ชายฝั่งในพื้นที่ที่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่ จึงต้องตีความบทกฎหมายดังกล่าวตลอดจนข้อกำหนดในกฎกระทรวงโดยเคร่งครัด จะตีความเพื่อขยายความให้เป็นผลร้ายแก่จำเลยหาได้หรือไม่ เพราะจะขัดต่อความรับผิดชอบของบุคคลในการรับโทษทางอาญาตาม ป.อ. มาตรา 2 วรรคหนึ่ง เมื่อกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 ซึ่งคู่ความนำสืบรับกันว่ามีผลใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดเหตุ ข้อ 1 กำหนดว่า ให้ยกเลิกความในข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "ข้อ 1 การอนุญาตให้เป็นมัคคุเทศก์ แบ่งเป็นสองประเภท ดังนี้ (1) มัคคุเทศก์ทั่วไป หมายความว่า

มัคคุเทศก์ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับงานนำเที่ยวครอบคลุมในทุกสาขา สำหรับนำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ (2) มัคคุเทศก์เฉพาะ หมายความว่า มัคคุเทศก์ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับงานนำเที่ยวเฉพาะสาขา เช่น สาขาประวัติศาสตร์ โบราณคดี และการนำเที่ยวป่า เป็นต้น อันเป็นการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในสาขานั้น ๆ ตามที่นักท่องเที่ยวต้องการจะทราบ..." และ ข้อ 2 กำหนดว่า ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 5 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "ข้อ 5 ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ก็มีสองประเภท ดังนี้ (1) ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ทั่วไป ให้ใช้ได้ทั่วราชอาณาจักรตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต (2) ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะ ให้ใช้ได้เฉพาะงานนำเที่ยวเฉพาะสาขาและตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต" จะเห็นว่าไม่มีข้อความตอนใดที่กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ให้ได้รับความชัดเจน ทั้งที่เหตุผลในการออกกฎกระทรวงท้ายกฎกระทรวงระบุว่า "มัคคุเทศก์เฉพาะปฏิบัติงานนำเที่ยวได้เฉพาะสาขาหรือเฉพาะพื้นที่.." แสดงถึงเจตนารมณ์ในการออกกฎกระทรวงที่ต้องการแยกเงื่อนไขในการใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะสาขาและเฉพาะพื้นที่ออกจากกัน ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเงื่อนไขการใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวซึ่งระบุว่าให้ใช้ได้เฉพาะงานนำเที่ยวเฉพาะสาขาจะหมายความว่ารวมถึงใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ด้วยหรือไม่ ประกอบกับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ของจำเลย ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขห้ามนำเที่ยวเฉพาะสาขาด้วยแล้ว กรณีจึงต้องตีความให้เป็นคุณแก่จำเลยว่า ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ บัตรสีชมพู ซึ่งออกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2539) ไม่มีเงื่อนไขที่กำหนดห้ามนำเที่ยวทางทะเลชายฝั่งในพื้นที่ที่ได้รับใบอนุญาต เมื่อพิจารณาเงื่อนไขในการใช้ใบอนุญาต

มัคคุเทศก์ชนิดต่าง ๆ มัคคุเทศก์เฉพาะทางทะเลชายฝั่ง บัตรสีเหลือง สามารถนำ
เที่ยวให้นักท่องเที่ยว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมััคคุเทศก์
พ.ศ. 2551 มาตรา 4, 49, 86

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและ
มััคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 มาตรา 49, 86 ให้รอกำหนดโทษจำเลยไว้มีกำหนด 1 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้แย้งกันในชั้นฎีการับฟังได้ว่า
จำเลยได้รับใบอนุญาตเป็นมััคคุเทศก์ ประเภทเฉพาะพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (ให้บริการนำ
เที่ยวแก่นักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ) บัตรสีชมพู ซึ่งสามารถนำเที่ยวใน
จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกันถึงจังหวัดกระบี่ นับตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่
1 ธันวาคม 2563 โดยใบอนุญาตดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจนำ
เที่ยวและมััคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 ต่อมาวันที่ 22 มิถุนายน 2561 มีการออกกฎ
กระทรวง การอนุญาตเป็นมััคคุเทศก์ พ.ศ. 2561 ตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง

แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และมาตรา 49 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามร้อยวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับและการออกใบอนุญาต การขอต่อและการต่ออายุใบอนุญาต และการขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ขึ้นใหม่ แต่ก่อนกฎกระทรวงฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับ ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์นำนักท่องเที่ยวของบริษัท ป. โดยสารเรือนำเที่ยวออกจากอ่าวปีละ บ้านเกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ และถูกจับกุมดำเนินคดีในความผิดฐานทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ต่อมาวันที่ 1 มีนาคม 2562 จำเลยผ่านการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้

มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 มาตรา 49 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กำหนดว่า ผู้ใดประสงค์จะเป็นมัคคุเทศก์ก็ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากนายทะเบียน การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งถือเป็นบทกฎหมายที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการประกอบอาชีพ และมีการกำหนดโทษทางอาญาไว้ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การพิจารณาว่าใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ บัตรสีชมพู มีเงื่อนไขห้ามนำเที่ยวทางทะเล

ชายฝั่งในพื้นที่ที่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่ จึงต้องตีความบทกฎหมายดังกล่าวตลอดจน
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงโดยเคร่งครัด จะตีความเพื่อขยายความให้เป็นผลร้ายแก่
จำเลยหาได้หรือไม่ เพราะจะขัดต่อความรับผิดชอบของบุคคลในการรับโทษทางอาญาตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคหนึ่ง เมื่อกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.
2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 ซึ่ง
คู่ความนำสืบรับกันว่ามีผลใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดเหตุ ข้อ 1 กำหนดว่า ให้ยกเลิก

(นิพนธ์ ใจสำราญ-ชูเกียรติ ดิลกแพทย์-ฉัตรทิศา ชัยรัชต์กร)

ศาลจังหวัดกระบี่ - นายธันวา ถนอมเกียรติ
ศาลอุทธรณ์ภาค 8 - นายชัยวัฒน์ เตชะวิจิตรชัย

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>